

1500402-08.2019.8.26.0530

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Guacy Sibille Leite

Comarca: Ribeirão Preto

Foro: Foro de Ribeirão Preto

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 17/01/2022

... somente incide a causa de aumento quando o tráfico está direcionado aos passageiros [...].

Desse modo, considerando-se que, nos casos ocorridos em estabelecimentos prisionais, utiliza-se o critério objetivo, ou seja, o primeiro entendimento, é irrelevante a intenção específica do agente. Destaco:

EMENTA Habeas corpus. Penal. Tráfico de drogas praticado nas imediações de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ribeirão Preto

Foro de Ribeirão Preto

3ª Vara Criminal

Rua Alice Alem Saadi, 1010, Ribeirão Preto-SP - cep 14096-570

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500402-08.2019.8.26.0530 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500402-08.2019.8.26.0530 - 239/19

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial - 2040863/2019 - DISE- DEL.SEC.RIBEIRAO PRETO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Kelly Cristina Marcari Borges

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Guacy Sibille Leite

Vistos.

KELLY CRISTINA MARCARI BORGES, qualificada nos autos, está sendo processada por incurso no artigo 33, caput, conjugado com o artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06, porque, segundo a acusação, na data de 10 de fevereiro de 2019, às 11h45min, nas dependências da Penitenciária Masculina desta cidade e comarca de Ribeirão Preto/SP, localizada na Rodovia Abraão Assed, km 47, zona rural ciente da ilicitude e da reprovabilidade de suas condutas, trazia consigo, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para fins de tráfico, as seguintes substâncias entorpecentes, 102,850g (cento e dois gramas, oitocentos e cinquenta miligramas) de maconha, embaladas com 1 (um) invólucro plástico de cor

preta (p.29).

Realizada audiência de custódia, contra a acusada foram impostas medidas cautelares diversas da prisão, resultando em sua liberdade (pp. 34/37).

A ré foi notificada (p. 68) e ofertou defesa preliminar (p. 72-75).

A denúncia foi recebida em 09 de agosto de 2019. (p.85) e a ré foi citada (p.99).

Durante a instrução, foram inquiridas as testemunhas e a ré foi declarada revel (p. 103-104), sendo posteriormente a revelia revogada (p.105).

Designada audiência de instrução, debates e julgamento, a prova oral foi colhida e interrogada a acusada KELLY CRISTINA M. BORGES, e foi recebido o testemunho de APARECIDA DE FÁTIMA OLIVEIRA por videoconferência com o uso da ferramenta Microsoft Teams.

Em memoriais, o Ministério Público pleiteou a total procedência da ação, com a consequente condenação da ré, nos termos da denúncia. Reconheceu, ainda, a primariedade da ré e a consequente causa de redução descrita no art. 33, § 4º, da Lei em comento, além da expressa confissão da ré possibilitar progressão no regime da pena.

Por sua vez, a Defesa pleiteou a absolvição, com base no artigo 386, incisos V ou VII, do Código de Processo penal; subsidiariamente, que se estabeleça a pena em seu mínimo legal, o reconhecimento do tráfico privilegiado, com a redução em seu patamar máximo, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a concessão do direito de recorrer em liberdade.

É o relatório.

Passo a fundamentar.

Procede a presente denúncia.

A autoria e a materialidade foram comprovadas pelo auto de prisão em flagrante (p.1), auto de exibição e apreensão (p.9-10), laudo pericial de constatação (p.17-18), exame químico toxicológico (p.50-51), bem como pela prova oral coligida.

O laudo de exame químico (p. 50-51) constatou que na substância apreendida foi detectada a presença de TETRAHIDROCANABINOL (THC), princípio ativo do vegetal "Cannabis sativa L", popularmente conhecida como "maconha". assegurando a materialidade do crime.

Em juízo, a testemunha Aparecida de Fátima Oliveira afirmou que, durante a passagem da ré pelo scanner, foi observado um objeto estranho na altura do quadril. Assim, Kelly foi encaminhada para uma sala separada, onde, de pronto, admitiu estar levando os entorpecentes para penitenciária e retirou o objeto espontaneamente. Por fim, completou que a ré não mencionou para quem seriam as drogas. Em consonância temos:

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. RECONHECIMENTO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS TESTEMUNHOS DE AGENTES PENITENCIÁRIOS. REAVALIAÇÃO DE ELEMENTOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.

INCOGNOSCIBILIDADE, NO PONTO. FALTA GRAVE. PERDA DOS DIAS REMIDOS. ELEIÇÃO DO PATAMAR MÁXIMO DESPROVIDA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. IMPOSSIBILIDADE DE ADOÇÃO DE CRITÉRIO OBJETIVO. PRECEDENTES. PEDIDO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que "a palavra dos agentes penitenciários na apuração de falta grave constitui prova idônea e suficiente para o convencimento do magistrado, haja vista tratarem-se de agentes públicos, cujos atos e declarações gozam de presunção de legitimidade" (...) (STJ - HC: 692749 SP 2021/0291550-2, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 21/09/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/10/2021).

Interrogada em juízo, a acusada confessou os fatos narrados na inicial acusatória. Esclareceu que, por estar precisando de dinheiro, aceitou levar as drogas à penitenciária por mil reais. Contudo, não soube dizer o nome do proponente. Ademais, acrescentou que não foi processada anteriormente, que está arrependida e não tem nada contra a testemunha. Ora, a confissão não é elemento isolado nos autos, ao revés, foi corroborada pelo conjunto probatório. Quanto à confissão judicial, vale destacar:

A confissão judicial livre, espontânea e não posta em dúvida por qualquer elemento dos autos pode levar à condenação do acusado. Já se tem decidido, por isso, que a confissão judicial é prova para a condenação, máxime quando compatível com a materialidade do delito e realizada na presença do defensor ou corroborada por depoimentos, mesmo do inquérito policial. (Júlio Fabbrini Mirabete - Processo Penal - ed. Atlas, 8a edição, pág. 288).

APELAÇÃO. FURTO SIMPLES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONFISSÃO. VALIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. FURTO CONSUMADO. DOSIMETRIA QUE NÃO COMPORTA ALTERAÇÃO. REGIME ABERTO MANTIDO. IMPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO. (...) 2. A confissão, de fato, não é prova dotada de caráter absoluto (aliás, no sistema processual penal em vigor, nenhuma prova tem esse caráter). Todavia, é importante elemento a ser considerado pelo julgador na formação do seu convencimento. Quando a confissão estiver em conformidade com os demais elementos dos autos, como ocorre neste feito, serve, sim, de supedâneo à prolação do edito condenatório. No caso, nada existe a indicar que a confissão não tenha sido firme e sincera. Com todo o respeito, apenas elucubrações anódinas, por assim dizer, as quais pouco ou quase nada auxiliam na apreciação do acervo probatório, poderiam, num caso como o presente, dar sustentáculo à conclusão de que a ré estaria mentindo, imputando a si, falsamente, o fato criminoso. Nada existe de concreto (nem mesmo de compreensível) a indicar a imprestabilidade da confissão judicial da apelante, mormente porque confirmada pela prova oral produzida em Juízo. (...) Precedentes do STF. (TJSP, Apelação nº 0002143-30.2010.8.26.0060, 3º Câmara de Direito Criminal, julgado em 31/10/2017).

Nesse sentido, a confissão da acusada vai ao encontro dos depoimentos testemunhais, formando um conjunto probatório harmonioso.

Diante desse quadro, o conjunto probatório aponta, de forma suficiente, ter a ré praticado o delito previsto no artigo 33, caput, conjugado com o artigo 40, inciso III da Lei 11.343/06, na forma descrita na denúncia.

Ainda que o ato de venda, em si, não tenha sido praticado ou observado pela testemunha, a condenação por tráfico não pode ser afastada. Isso porque o artigo 33 da Lei 11.343/2006 dispõe que o ato de trazer consigo a droga já configura o tipo penal. Em consonância, destaco a seguinte decisão do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, cuja tese está consolidada na edição nº 131 do Caderno Jurisprudência em teses:

"O crime de tráfico de drogas é tipo misto alternativo restando consumado quando o agente pratica um dos vários verbos nucleares inserido no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, sendo a venda prescindível ao seu reconhecimento" (HC 382.306/RS, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 7/2/2017, DJe de 10/2/2017). 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RESp 1807400/RS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 28/08/2019)"

Por oportuno, "convém ressaltar que a flagrância talvez seja a prova mais eloquente do crime e da respectiva autoria" (conforme Tornaghi, in "Curso de Processo Penal", 5ª ed., II/49; TACRIM - SP 43/251; 50/218 - 219).

Não se pode olvidar que o art. 40, III, da Lei nº 11.343/2006 determina o aumento de pena quando se tratar de tráfico em estabelecimento prisional, assim como ocorreu no caso em tela. Conforme discorrido por José Paulo Baltazar Jr., há duas possibilidades de interpretação acerca do caráter dessa causa de aumento:

[...] Para a primeira, a causa de aumento é objetiva, bastando à sua incidência que o fato tenha ocorrido em um dos locais mencionados, independentemente de qualquer intenção específica do agente ou resultado concreto [...]. Adotada essa orientação, aplica-se a majorante para aquele que transporta a droga como passageiro em ônibus de linha, independentemente de efetiva distribuição de droga naquele local [...].

Para a segunda, exige-se que o comportamento ostensivo do agente tenha, de algum modo, estimulado a utilização por terceiros [...]. Nessa linha, já se afirmou, quanto aos transportes públicos, que somente incide a causa de aumento quando o tráfico está direcionado aos passageiros [...].

Desse modo, considerando-se que, nos casos ocorridos em estabelecimentos prisionais, utiliza-se o critério objetivo, ou seja, o primeiro entendimento, é irrelevante a intenção específica do agente. Destaco:

EMENTA Habeas corpus. Penal. Tráfico de drogas praticado nas imediações de estabelecimento prisional (art. 33 c/c o art. 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06). Insurgência contra os pressupostos de admissibilidade do recurso interposto perante o Superior Tribunal de Justiça. Inadmissibilidade de discussão na via do habeas corpus. Precedentes. Afastamento da causa de aumento de pena do art. 40, inciso III, da Lei de drogas. Impossibilidade. Constatação de comercialização de drogas nas imediações de estabelecimento prisional. Motivo hábil que autoriza a incidência da causa de aumento da pena. Irrelevância de o agente infrator visar os frequentadores daquele local. Precedentes. Ordem denegada. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal está sedimentada na impossibilidade do uso do habeas corpus para se reexaminarem os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 2. A aplicação da causa de aumento prevista no art. 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06 se justifica quando constatada a comercialização de drogas nas imediações de estabelecimentos prisionais, sendo irrelevante se o agente infrator visa ou não os frequentadores daquele local. Precedentes. 3. Ordem denegada. (HC 138944, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 21/03/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-170 DIVULG 02-08-2017 PUBLIC 03-08-2017)

Verifica-se, portanto, que a prova oral produzida e os elementos coligidos se revestem de coerência, robustez e segurança e não demonstram qualquer tendência para o exagero ou o prejuízo injusto, sendo hábeis à condenação.

Afora isso, vale dizer que nenhum elemento foi trazido à baila que pudesse desmerecer os depoimentos coerentes prestados em juízo, a respeito da realidade retratada, ou que pudesse afastar o decreto condenatório. Assim, o quadro probatório é suficiente para embasar a decisão condenatória.

Ante o exposto, conclui-se pela procedência da ação, nos exatos termos da denúncia. Passo à dosagem de pena.

Considero as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal e art. 42 da Lei de Drogas como as normais do tipo e fixo a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, não há agravantes a serem consideradas. Por outro lado, verifico a presença da circunstância atenuante da confissão espontânea, mas deixo de diminuir a pena, visto que esta já se encontra no mínimo legal.

Na terceira fase, verifico a incidência da causa de diminuição descrita no artigo 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006, pois a ré é primária e de bons antecedentes, e não há indícios de que se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa. Portanto, diminuo a pena em 2/3 (dois terços).

Aumento a pena em 1/6 (um sexto), em virtude da majorante prevista no artigo 40, III, da Lei 11.343/06, haja vista que o tráfico se deu em estabelecimento prisional.

Ausentes outras causas modificativas, torno definitiva a pena em 01 (um) ano e 11 (onze) meses de reclusão e pagamento de 193 (cento e noventa e três) dias-multa.

Fixo o regime inicial aberto, tendo em vista a primariedade e o quantum da pena aplicada, segundo disposição do artigo 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal.

Presentes os requisitos do artigo 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, dada a condição financeira da ré, conforme o §2º do mesmo dispositivo.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para CONDENAR KELLY CRISTINA MARCARI BORGES, qualificada nos autos, por incurso no artigo 33, §4º, da Lei n.

11.343/2006, à pena privativa de liberdade de 01 (UM) ANO E 11 (ONZE) MESES DE RECLUSÃO, em regime inicial aberto, além do pagamento de 193 (CENTO NOVENTA E TRÊS) DIAS-MULTA, no valor unitário mínimo, dada sua condição financeira desfavorável, com os reajustes legais.

Por inteligência do artigo 44, §2º, do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana, pelo prazo da pena corporal, com carga horária semanal mínima, a ser definida pelo Juízo das Execuções Criminais.

Faculto a ré o direito a recorrer em liberdade.

Com fundamento no artigo 804 do Código de Processo Penal e artigo 4º, parágrafo 9º, alínea "a", da Lei Estadual nº 11.608/2003, o acusado arcará com valor equivalente a 100 UFESPs, a título de custas, ressalvado o disposto no artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil (gratuidade da justiça deferida no item "2" de p. 85).

Determino a incineração da droga apreendida, caso ainda não tenha sido efetuada na forma do artigo 50-A da Lei nº 11.343/2006.

Transitada em julgado, comunique-se ao Tribunal Regional Eleitoral (artigo 15 inciso III, da Constituição Federal) e expeça-se guia de execução.

P.R.I.C.

Ribeirão Preto, 17 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA